

0000453-82.2017.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Por fim, em caso de condenação pelo tráfico, requereu que a pena fosse estabelecida no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da menoridade relativa.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/04 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000453-82.2017.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000453-82.2017.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 1123/2017 - Delegacia de Polícia de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DA SILVA BREBAL HESPANA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de DANIEL DA SILVA BREBAL HESPANA, qualificado nos autos, na qual lhe é atribuída a prática dos crimes tipificados nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, pelos fatos narrados na exordial de fls. 185/190.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado à fl. 231, apresentando defesa prévia às fls. 235/236. Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 09/01/2018 (fls. 237), com designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos dos artigos 56 e seguintes, da Lei 11.343/06 (fls. 259/260).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas, e interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, sendo o feito sentenciado (fls. 266/276). Contudo, a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça em 26/09/2019, devido a problemas técnicos com as provas orais (fls. 351/354).

Nesse escopo, designou-se nova audiência de instrução e julgamento (fls. 437), sendo a prova oral renovada, realizando-se novo interrogatório. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais em audiência (mídia à fls. 438).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e sua absolvição, por insuficiência probatória, no tocante ao delito do artigo 35, "caput", da mesma lei.

Por sua vez, a defesa requereu a improcedência da ação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de não haver provas concretas com relação à traficância por parte do acusado. Com relação ao delito do artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, a defesa acompanhou a manifestação do Ministério Público, pleiteando sua absolvição. Por fim, em caso de condenação pelo tráfico, requereu que a pena fosse estabelecida no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da menoridade relativa.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/04 e 05/07), boletim de ocorrência (fls. 15/19), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo de constatação provisória (fls. 33/34) e laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 256/258), cujos resultados foram positivos para "cocaína e tetrahidrocannabinol - THC - maconha", substâncias presentes nas listas da portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores; bem como pelas provas orais colhidas em Juízo.

A prova de autoria, igualmente restou confirmada nos autos, ao menos quanto ao crime do artigo 33, "caput" da Lei de Tóxicos. Senão vejamos.

O policial militar atualmente na reserva, Benedito Cesar da Fonseca, contou que era de conhecimento do Pm. Nilton que Daniel e Júlio realizavam o tráfico de drogas em frente à casa deste último, sendo que, ao se deslocarem até o local, a dupla, ao notar a presença da viatura, pulou o muro e caiu em um terreno baldio, momento em que os policiais Nilton e Rodrigo adentraram ao local, onde ocorreu todo o desfecho da estória. O depoente esclareceu que como os fatos se passaram no interior do terreno, não tem condições de explicar a sua dinâmica. De acordo com a testemunha, em razão dos familiares de Júlio imporem dificuldades a entrada dos agentes públicos no local foi necessário solicitar apoio de outros policiais. Por fim, confirmou ser sua, a assinatura aposta no documento de fls. 12 (depoimento em sede policial).

Já o policial militar, Nilton César Moreira da Silva, iniciou seu depoimento dizendo que à época dos fatos, o local em questão era altamente conhecido por abrigar um ponto de tráfico de drogas, embora atualmente a situação esteja mais tranquila. Sobre os fatos, esclareceu que naquele local morava Júlio César e seus familiares, e sempre a polícia recebia diversas denúncias relacionadas ao vil comércio e de pessoas armadas no lugar, no entanto, os familiares de Júlio, moradores das proximidades, sempre dificultavam as operações policiais no local. Assim, já conhecendo a situação, a "Força Tática" (braço da polícia militar na

região, responsável pelo patrulhamento das vias), montou uma operação, a fim de apreender armas e entorpecentes, na data dos fatos. Para tanto, três viaturas foram deslocadas até o local. Conhecedores da rota de fuga utilizada pelos criminosos naquela região, alguns policiais ficaram monitorando a passagem, enquanto outros dirigiram-se até o portão da residência para realizar a abordagem. Como previsto, ao avistarem a viatura, Júlio e Daniel saíram correndo, momento em que os familiares partiram para cima dos policiais, como de costume, contudo, o depoente, juntamente com o policial Fábio Rodrigo, entraram pelos fundos e, com o auxílio de uma lanterna, puderam avistar Daniel e Júlio César, este último com uma arma de fogo em punho. À vista da situação, determinaram que Júlio César soltasse a arma, ordem esta por ele não respeitada. Assim, o policial Fábio Rodrigo efetuou disparos em sua direção, tendo um deles o atingido fatalmente, e um outro, acertado o acusado, em seu pé. Ao realizarem os socorros, perceberam que havia uma sacola repleta de drogas caída no chão. Esclareceu que Daniel já possuía passagens anteriores relacionadas à drogas, com a adolescência marcada por atos infracionais análogos ao tráfico. Explicou, inclusive, que dias antes do fato, ora julgado, o réu havia sido surpreendido na posse de uma sacola contendo entorpecentes, no mesmo local, entretanto, naquela ocasião, logrou fugir, sem ser detido. Questionado, contou que não chegou a visualizar qual dos dois (Júlio ou Daniel) estava com a sacola contendo entorpecentes, reafirmando que a mesma encontrava-se próxima aos dois. Frisou que, de acordo com as informações que a polícia dispunha à época, Daniel e Júlio César praticavam juntos o tráfico de drogas com o apoio da família deste último. Por fim, a testemunha esclareceu que o terreno baldio onde a dupla foi alvejada era justamente a rota de fuga que sempre utilizavam para fugir da polícia.

Seu companheiro de farda, Fábio Rodrigo de Oliveira, fez eco à suas palavras.

Por outro lado, o acusado durante o ato destinado à sua autodefesa, negou os fatos. Disse que é usuário de drogas, e que sempre frequentava o local dos fatos para buscar entorpecentes para seu próprio consumo, e nunca para traficar. De acordo com o interrogando, na ocasião, estava comprando drogas de Júlio César. Contou que já havia entregue o numerário relativo à compra ao falecido (Júlio César), e o aguardava buscar o entorpecente. Quando Júlio César retornava ao ponto de encontro para lhe entregar as drogas, uma viatura apareceu no local. Nesse momento, Júlio César correu e lhe pediu para que o acompanhasse. Esclareceu que, por estar entorpecido, acabou tentando correndo e, na sequência, ambos pularam o muro da residência, logo se escondendo atrás de uma árvore, enquanto Júlio César passou a engolir os entorpecentes para que a polícia não os encontrassem. Na sequência, os policiais pularam o muro e efetuaram disparos, negando que Júlio César estivesse segurando qualquer arma de fogo, mas apenas uma sacola contendo entorpecentes. Afirmou que o policial Nilton já efetuou a prisão de seu irmão algumas vezes, motivo pelo qual, não sabe dizer se isso o influenciaria a querer lhe incriminar injustamente. Por fim, informou que já cumpriu medida socioeducativa de internação e liberdade assistida, enquanto menor.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a prova oral demonstrou que o réu, de fato, estava na posse dos entorpecentes apreendidos pela polícia, ainda que em coautoria com Júlio César, já falecido.

Por outro lado, insta registrar, como já sustentado em outras oportunidades, que aqueles que acompanham de perto as decisões deste Magistrado, bem sabem a credibilidade que costumo conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Tribunal de Justiça deste estado – TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decísium o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Destarte, fixada tal diretriz, observo que o caso, ora em apreço, é mais um dentre tantos outros vistos no dia-a-dia forense, no qual o réu tenta, em vão, desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzir sequer um início de prova de sua alegação, buscando assumir conduta menos gravosa (aquela abarcada no artigo 28, da Lei 11.343/06), e atribuindo o narcotráfico ao seu comparsa, morto durante a operação ação policial.

Neste ponto, há que se destacar aqui, a postura sóbria e prudente das testemunhas arroladas pela acusação, as quais em nenhum momento buscaram confirmar suas narrativas a qualquer custo, demonstrando cuidado e responsabilidade em Juízo, quando disseram, por exemplo, que a sacola contendo os narcóticos estava ao chão, próximo ao réu, bem como de Júlio Cesar.

Ou seja, estivéssemos diante de policiais militares mal-intencionados, o que, frise-se, está longe de ser uma realidade nos quadros da polícia militar bandeirante, e, especialmente das testemunhas de acusação deste feito, possivelmente os relatos a respeito da conduta post factum do acusado seriam diversos, no sentido de o comprometer, asseverando que a sacola estava em sua posse, algo que não se viu, conforma já destacado alhures.

Outro ponto a demonstrar a confiabilidade da palavra dos policiais militares envolvidos nessa ocorrência em detrimento à do acusado, é que aqueles mantiveram a narrativa apresentada, em delegacia de polícia (fls. 08/09, 10/11 e 12), em Juízo, ao contrário do réu que, naquela seara, nada dissera, pois, sob a orientação de sua advogada, preferiu fazer uso do silêncio (fls. 43).

Ora, se por um lado, tal postura revela o exercício de um direito assegurado constitucionalmente ao acusado, não podendo ser prejudicado por essa razão, de outro, nesse caso específico, causa estranheza o réu deixar de levar ao conhecimento da autoridade policial, integrante da polícia civil (como se sabe, distinta daquela que realizou a prisão), a alegada conduta ilegal e irresponsável

dos policiais militares, que, segundo sua versão, buscam incriminá-lo injustamente. Afinal, se fosse real o enredo trazido em pretório, por que não assumir, de plano, a prática da conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, ao delegado de polícia?

Como é de conhecimento comum, ainda mais acompanhado por advogada constituída, a conduta delituosa do usuário de drogas sofreu despenalização e, atualmente, ainda que criminosa, é considerada de menor potencial ofensivo, até mesmo, de competência dos Juizados Especiais Criminais, não havendo razão para o acusado preferir ter a sua prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial quando, por outro lado, assinaria termo de compromisso em comparecer em juízo e seria liberado.

Lado outro, sem prejuízo da certeza do envolvimento de Daniel no tráfico, com Júlio Cesar, trazido pelos depoimentos policiais, é que a sua própria versão defensiva indica a traficância.

Primeiro, o fato do réu e Júlio César terem se evadido na mesma direção, no exato momento em que notaram a presença dos policiais, é um claro indicativo de que estavam conluiados para fins da mercancia ilícita. Não faz qualquer sentido o réu ter fugido com o suposto traficante com quem negociava, apenas por este lhe ter solicitado que assim o fizesse.

Segundo, se realmente ali a dupla estava negociando drogas, por qual motivo não foi encontrado dinheiro com nenhum deles?

Destarte, encampar a versão defensiva de Daniel, apenas confiando em sua palavra, sem o mínimo lastro probatório, significaria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, diante do farto conjunto de provas pela sua autoria, em concurso de agentes com Júlio César, como, também, desprestigiar as declarações das testemunhas policiais, conforme vimos acima.

Ainda que verdadeiro que o increpado seja usuário de drogas, tal circunstância não afasta a tipicidade de sua conduta pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, até por não ser incompatível que usuários também trafiquem, eventualmente.

Decerto, não raro usuários passam a vender drogas com o fim de financiarem a própria dependência, salientando-se, no entanto que, no caso dos autos, a quantidade elevada de narcóticos apreendida demonstra que esta não se destinaria exclusivamente ao consumo de Daniel. Refuta-se, assim, a tese defensiva de desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

"Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso". (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Por fim, cabe apontar que é desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, conforme acima fundamentado.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, o caso é mesmo de condenação de Daniel, pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Lado outro, com relação ao crime do artigo 35, “caput”, da Lei em assunto, o destino do acusado é a absolvição, em linha com os pedidos das partes.

Convém lembrar que não basta para subsumir a conduta em estudo ao tipo do artigo 35, da legislação de drogas, a presença de dois ou mais agentes. É imprescindível que se revele o “animus associativo”, a estabilidade, permanência e organização do grupo, com funções pré-determinadas entre seus membros, bem como relação de hierarquia entre eles.

No caso, ainda que os policiais militares tenham afirmado que Daniel estava sempre com Júlio César naquela vil empreitada, não existem nos autos, outras provas a demonstrar os requisitos do tipo penal, ora em voga, acima elencados.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação. (...) Associação – provas insuficientes. O crime em tela exige a vontade de dois ou mais agentes se associarem (animus associativo) e sua consumação se dá com a reunião estável e permanente, dispensando a prática do crime-fim. Não se demonstrou, contudo, mínima organização e hierarquia entre eles o que, após cotejar todos os elementos analíticos inseridos nos autos, não emerge com clareza meridiana o vínculo associativo. (...) Recurso parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão”. (TJSP; Apelação Criminal 0002107-90.2016.8.26.0443; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piedade - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017) (Ênfase minha).

Assim, embora tenha ficado expresso nos autos que o réu praticou o crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 em coautoria com o falecido Júlio César, a acusação não comprovou, suficientemente, a participação em associação criminosa. Portanto, quanto à imputação remanescente, impõe-se a absolvição do acusado.

Passo à calibragem penal.

Na primeira fase da aplicação da pena, verifico que o acusado possui uma condenação, conforme certidão de fls. 429/431 (autos nº 0002363-68.2017.8.26.0323, trânsito em julgado em 24/02/2020), pelo mesmo crime destes autos.

Ainda nesta etapa, observo que a quantidade e diversidade de entorpecentes

apreendidos revelam maior reprovabilidade da conduta censurada. Afinal, considerando que o tipo penal em questão visa tutelar o bem jurídico saúde pública, tão caro à sociedade, não valorar negativamente aquele que é surpreendido na posse de 32,37 gramas, peso líquido, de "cocaína"; 52,96 gramas, peso líquido, de "crack"; e 31,95 gramas, peso líquido, de "maconha"; significaria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar tal conduta àquelas nas quais envolvem apreensão de pequena quantidade.

Ademais, como se vê, uma das espécies de drogas era justamente o maldito "crack", de enorme capacidade de viciar, como é notório e alardeado por toda a mídia.

No mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - (...) Posse de significativa quantidade de drogas, de naturezas variadas, dentre elas o 'crack', estupefaciente altamente nocivo - (...) Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada".

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2156763-63.2021.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021); e

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...). Base corretamente fixada em 1/6 acima do piso, tendo em vista a natureza especialmente deletéria das substâncias, notadamente o crack (art. 42 da Lei nº 11.343/06). (...). Recurso defensivo desprovido".

(TJSP; Apelação Criminal 1500225-67.2020.8.26.0608; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021) (Sublinhados meus).

Portanto, diante dessas circunstâncias judiciais negativas, tenho por bem fixar a pena-base acrescida de 1/4 (um quarto) do piso legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na fase intermediária, reconheço a menoridade relativa do acusado. Logo, atenuo as penas em 1/6 (um sexto), finalizando-as em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, por não haver outras circunstâncias alteradoras.

Apenas para que não seja alegada omissão desta sentença, esclareço ser inviável a concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, conforme o próprio texto legal, à vista do seu mau antecedente do réu.

Outro não é o entendimento do E. TJSP:

"Embargos de declaração - (...) - Novo entendimento do STF em relação aos maus antecedentes em sede de repercussão geral - Possibilidade de se considerar, para tais fins, condenação cuja punibilidade esteja extinta há mais de cinco anos - Os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado - Possibilidade, com isso, de valoração negativa da quantidade e variedade de entorpecentes na primeira fase, exasperando-se as básicas - Regime inicial alterado para o fechado, diante da quantidade de pena imposta e dos maus antecedentes". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500561-12.2019.8.26.0542; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020) (Sublinhado meu).

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pontue-se estarmos diante do delito de tráfico, crime este equiparado à hediondo, de acordo com a atual redação do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Por tal razão, não se mostra razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não seja obrigatório o regime mais gravoso, ante o reconhecimento pelo C. Supremo Tribunal Federal – STF, em caráter incidental, da inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que tal não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

No caso dos autos, impõe-se o regime fechado, em vista das circunstâncias concretas acima expostas, reforçando-se, como exemplo, a quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como o mau antecedente de Daniel, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar DANIEL DA SILVA BREBAL HESPANA, qualificado nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da multa de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, diária mínima (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Ainda ante ao exposto, o absolvo da imputação da imputação remanescente que lhe foi irrogada na denúncia (35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06), assim o fazendo, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de medidas despenalizadoras ao caso, à vista do montante de pena aplicada, ou mesmo do passado criminal desabonador do réu.

Concedo-lhe, no entanto, o recurso em liberdade, em respeito à decisão da Instância Superior (fls. 351/354), até por não vislumbrar a existência de nenhuma motivo, após a restauração da liberdade do réu, que indicasse a necessidade de nova decretação de prisão provisória.

Custas pelo vencido.

Encaminhem-se as drogas apreendidas, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição, expedindo-se o necessário.

Já, com relação à arma de fogo, apreendida na mesma oportunidade, determino a remessa ao Exército, para as finalidades cabíveis, do revólver apreendido à fl. 21, nos termos do que dispõe o artigo 25, da Lei 10.826/03. Registro que a arma de fogo do policial militar, apreendida às fls. 20, já teve decisão para sua restituição

(fls. 374/375).

Com relação ao celular apreendido às fls. 23/24, nada fora produzido nos autos indicando o emprego desse aparelho no crime destes autos, ou mesmo de que era produto do mesmo e de qualquer outro delito. Assim, intime-se a quem de direito, que deverá apresentar prova idônea de sua propriedade, para retirá-lo. Não sendo tal aparelho reclamado, no prazo referido no artigo 123, do Código de Processo Penal, deverá ser vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes, salvo se não apresentar mais conteúdo econômico. Nesse caso, após a devida certificação nos autos, fica autorizada sua destruição, observadas as disposições normativas pertinentes.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandado de prisão, e, com a sua captura, a guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se com baixa.

P.I.C.

Lorena, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA